

1500144-42.2021.8.26.0622

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renato Hasegawa Lousano

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... as autoras, contudo, apenas do crime de tráfico de entorpecentes.

Vejamos.

Em juízo foram ouvidas duas testemunhas e o réu foram interrogadas.

A testemunha AMÉRICO ANANIAS, policial militar, narrou que o local é muito conhecido pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Fizemos patrulhamento no local e inclusive abordamos as acusadas, mas nada foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

1ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444 -, (15) 2153-1827 - Criminal - Vila Ophélia

CEP: 18400-818 - Itapeva - SP

Telefone: (15) 2153-1829 - E-mail: itapeva1@tjsp.jus.br

1500144-42.2021.8.26.0622 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500144-42.2021.8.26.0622

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ÉRICA DE PROENÇA RODRIGUES e outro

Juiz de Direito: Dr. Renato Hasegawa Lousano

Vistos.

ERICA DE PROENÇA, qualificada às fls. 07 e KELEN GILMARA DE PROENÇA RODRIGUES, qualificada às fls. 08, foram denunciadas perante este Juízo como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III c.c artigo 35, todos da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo consta, no dia 03 de junho de 2021, por volta das 23:25 horas, na Rua Sebastião Melo, 120, nesta cidade e comarca de Itapeva/SP, guardavam, para fins de tráfico, 23 (vinte e três) porções de crack, com peso bruto de 3.06g (três gramas e seis centigramas), 45 (quarenta e cinco) invólucros de maconha, com peso bruto de 101.81g (cento e uma grama e oitenta e um centigramas) e 79 (setenta e nove) microtubos de cocaína, com peso bruto de 57.92g (cinquenta e sete gramas e noventa e duas centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, nas imediações de estabelecimento de ensino, entidade religiosa e espaço de esportes.

Consta, também, que desde data incerta mas até a data de 03 de junho de 2021, por

volta das 23:25 horas, na Rua Sebastião Melo, 120, nesta cidade e comarca de Itapeva/SP, ERICA DE PROENÇA RODRIGUES e KELEN GILMARA DE PROENÇA RODRIGUES associaram-se para o fim de praticar, ainda que não reiteradamente, o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/2006.

Conforme decisão de fls. 79/82, foi convertida a prisão em flagrante das rés em prisão preventiva.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial, e foi recebida às fls. 189. As rés foram notificadas às fls. 170 e 172 e apresentaram defesa prévia às fls. 179/180 e 187/188.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas e as rés foram interrogadas.

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido condenatório nos termos da peça vestibular. A Defesa de ÉRICA requereu a absolvição da acusada pelo crime de associação para o tráfico, o afastamento das causas de aumento a e aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. No mesmo sentido a Defesa da acusada KELEN.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada parcialmente procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, não restaram devidamente comprovados todos os fatos delituosos descritos na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade do encontro do entorpecente é indubitosa, porquanto demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), boletins de ocorrência (fls. 13/16), auto de exibição/apreensão (fls. 17/18), laudos de constatação provisória e definitivos de substância entorpecente (fls. 24/34 e 133/136, 138/149), relatório de investigação (fls. 130/131) e relatório final da autoridade policial (fls. 151/155), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria dos fatos também está sobejamente comprovada, porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais, no sentido de lhes apontar como sendo as autoras, contudo, apenas do crime de tráfico de entorpecentes.

Vejamos.

Em juízo foram ouvidas duas testemunhas e o rés foram interrogadas.

A testemunha AMÉRICO ANANIAS, policial militar, narrou que o local é muito conhecido pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Fizemos patrulhamento no local e inclusive abordamos as acusadas, mas nada foi encontrada com ela. Como os traficantes se dispersam quando veem a viatura, desembarcamos e fomos a pé para realizar buscas nos imóveis desabitados da região, que são usados para o tráfico. Adentramos na garagem de uma das casas, que não tem iluminação, e nesse momento ouvimos uma motocicleta parar e uma voz feminina dizer "pega 4 pós". A KELEN adentrou bem no imóvel em que nós estávamos e pegou um pote branco próximo a um poste de energia. Nós a paramos e nesse pote tinha crack e cocaína. Conseguimos abordar também A ERIKA, que era dona daquela voz que pediu a droga. A ERIKA admitiu que a droga era dela. A KELEN confessou que estaria ajudando em razão de dificuldades financeiras. A ERIKA informou que havia maconha dentro de um saco de roupas no interior da casa. Não havia nada na residência. Fogão, geladeira, nada. Havia uma cama e um colchão velho em um dos quartos. Até hoje essa residência está

fazia. Aberta e sem trancas nas portas.

A testemunha CLAUDIO MARTINS, policial militar, narrou os fatos de maneira harmônica como seu colega de farda, acrescentando que a casa é utilizada para guardar droga por um bom tempo. Acrescentou também que o tráfico no local é muito organizado e que os traficantes utilizam essas casas desabitadas para guardar a droga, e com a chegada dos policiais os olheiros assobiam e os traficantes se evadem de frente das casas e não conseguimos localizar os entorpecentes.

A ré ERICA DE PROENÇA foi ouvida em duas oportunidades. Na fase inquisitorial, INTERROGADA pela autoridade, declarou "informo que são verdadeiros, pois estou passando dificuldades financeiras e resolvi traficar. as drogas me pertencem, sendo que minha irmã apenas me auxilia na venda. confirmo que guardava as drogas na residência onde os policiais as localizaram" (fls. 07/08).

Interrogada em juízo, disse que são verdadeiras as acusações. Eu estava precisando e por isso passei a traficar. A minha irmã trabalhava com produtos da Avon e nesse dia eu pedi ajuda para ela. Eu combinei com a minha irmã de dividir o dinheiro com ela naquele dia. Eu busquei a droga em São Paulo. Eu estava traficando no local há cerca de duas semanas. Não morava ali. Era uma casa abandonada. Eu nunca tinha traficado e ia parar assim que vendesse tudo. Eu não ia buscar mais entorpecentes. Tenho 26 anos e morava sozinha com meus filhos de 8 (menina) e 3 (menino) anos. Os fatos aconteceram como os policiais relataram. Estão com a avó paterna e com minha irmã. Nenhum dos pais ajudam e eu precisava de dinheiro. O pai do meu filho estava preso. Eu nunca fui processada.

A ré KELEN GILMARA DE PROENÇA RODRIGUES também foi ouvida em duas oportunidades. Na fase inquisitorial, INTERROGADA pela autoridade, declarou "sou usuária de droga tipo maconha. nunca fui presa ou processada antes. sobre os fatos informo que realmente estava pelo local e iria pegar as drogas na casa onde estavam os policiais. mas afirmo que tais drogas não me pertencem. eu apenas auxílio minha irmã na venda. sou a responsável por retirar as drogas da casa e guardar o dinheiro na bolsa." (fls. 07/08).

Interrogada em juízo, declarou que os fatos ocorreram como narrado pelos policiais. Eu estava ajudando a minha irmã há dois dias. Minha mãe faleceu em agosto de 2020. Eu estava precisando do dinheiro. Minha filha de tem cinco anos. Eu estava morando com minha companheira e minha filha. Hoje ela está como a minha vó. Tenho 19 anos. Eu trabalhava vendendo cosméticos, mas o dinheiro era pouco.

Pois bem, encerrada a instrução processual, e debruçando-me detidamente sobre as provas produzidas em juízo, estou convencido da prática criminosa do tráfico de entorpecentes pelas acusadas.

Com efeito, a localização dos entorpecentes é certa e foi inclusive confessada pelas corrés.

A finalidade de comércio ficou evidenciada pela quantidade de drogas e sua forma de acondicionamento, já embalados para venda, bem como pelo dinheiro trocado encontrado com o réu, típico nesta espécie de comércio ilícito. constatou-se a ausência de qualquer indício de que os policiais militares vieram em Juízo para prejudicar as rés, sendo pelo próprio confirmado que não tem nada contra aqueles.

Contudo, não estou convencido da existência de associação criminosa entre as acusadas. Com efeito, é possível que as irmãs continuassem se dedicando à traficância, e com o passar do tempo realmente se organizassem de maneira definitiva e estável para a prática do tráfico de entorpecentes.

Porém, nesse momento, não há elementos para afastar a afirmação das vítimas, irmãs,

de que se tratava de uma prática ocasional, e que a KELEN foi auxiliar a irmã desde o dia anterior. Em outro giro, não como se afastar de que se tratou de mera coautoria ocasional.

Anoto que as rés são primárias, e não portadoras de maus antecedentes, sendo este o primeiro processo criminal respondido por ambas, reforçando a impressão tida em audiência.

Nesse sentido precedente do E. TJSP:

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Apelos defensivos buscando a absolvição dos réus - Acolhimento - Prova da permanência e da estabilidade indispensável - Requisitos necessários para a tipificação do crime - Fragilidade - Possibilidade de mero concurso de agentes - Dúvida que favorece os réus - Recurso provido para absolver. TRÁFICO DE DROGAS - Apelo defensivo visando à absolvição do réu Edivaldo ou à desclassificação - Prova segura e convincente - Confissão dos réus corroborada pelos depoimentos policiais - Desclassificação incabível - Circunstâncias indicativas da finalidade mercantil - Natureza e quantidade de entorpecentes individualmente embalados - Condenação mantida - Dosimetria - Redução do acréscimo da pena-base - Possibilidade - Privilégio incabível, diante da apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas, a demonstrar que os Apelantes têm profundo envolvimento com a atividade criminosa - Regime semiaberto suficiente - Preliminar afastada - Recursos parcialmente providos. (TJSP; Apelação Criminal 0000941-50.2016.8.26.0628; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeverica da Serra - 2ª Vara; Data do Julgamento: 25/04/2022; Data de Registro: 25/04/2022)

Especificamente sobre a causa de aumento de pena, sedimentou-se no E. STJ que é desnecessário que o tráfico ocorra durante o horário de aulas, ou mesmo que se destine aos frequentadores do estabelecimento de ensino.

Nesse sentido: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. COMETIMENTO DO CRIME NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA. COMPROVAÇÃO. REQUISITO SUFICIENTE PARA MAJORAÇÃO DA PENA. INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico se dava naquelas entidades ou que a mercancia se destinava a seus frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido em suas imediações, conforme comprovado pelo laudo pericial. Precedentes. (AgRg no HC 488.403/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 8/4/2019). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RESp 1838350/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

A causa de aumento, de resto, está comprovado pelo relatório de investigação de fls. 130/131

Assim sendo, o conjunto probatório é seguro e autoriza o decreto condenatório das rés, nos termos do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III da Lei nº 11.343/2006.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, com preponderância do art. 42 da Lei 11.343/06.

Ré ERICA DE PROENÇA

Conforme Folha de Antecedentes e Certidão de Distribuições Criminais juntadas às fls. 55/56 e 59/60, a ré é primária e não ostenta maus antecedentes. Não há

elementos para a ponderação das demais circunstâncias judiciais. Não obstante, por se tratar de relevante quantidade de entorpecentes, entre eles o crack e a cocaína, de grande poder viciante e efeitos devastadores, a aplicação direta do art. 42 da Lei 11.343/06 - "quantidade" e "natureza" da droga, permite a fixação de sua pena base acima do mínimo legal, majorando-a em 1/6.

Na segunda fase de fixação da pena não há agravantes. Incidente a atenuante da confissão, retorno a pena base para o mínimo legal.

Quanto à terceira fase, incide a causa de aumento prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei 11.343/06, uma vez que o comércio das drogas ocorria nas imediações de estabelecimento de ensino, entidade religiosa e espaço de esportes, conforme relatório policial e prova oral produzida em audiência, de modo que a pena deve ser aumentada em 1/6, a saber.

A ré preenche os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, vez que é primária, de bons antecedentes e não há informações nos autos de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa. Considerando o até aqui já apreciado para fixação de sua pena, a redução deve se dar na expressão intermediária (1/2).

Ausentes motivos idôneos, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um dias-multa), fixados estes no mínimo legal unitário.

RÉ KELEN GILMARA DE PROENÇA RODRIGUES

Conforme Folha de Antecedentes e Certidão de Distribuições Criminais juntadas às fls. 57/58, 61/62, 63/64, a ré é primária e não ostenta maus antecedentes, Não há elementos para a ponderação das demais circunstâncias judiciais. Não obstante, por se tratar de relevante quantidade de entorpecentes, entre eles o crack e a cocaína, de grande poder viciante e efeitos devastadores, a aplicação direta do art. 42 da Lei 11.343/06 - "quantidade" e "natureza" da droga, permite a fixação de sua pena base acima do mínimo legal, majorando-a em 1/6.

Na segunda fase de fixação da pena não há agravantes. Incidente a atenuante da confissão e da menoridade relativa, retorno a pena base para o mínimo legal.

Quanto à terceira fase, incide a causa de aumento prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei 11.343/06, uma vez que o comércio das drogas ocorria nas imediações de estabelecimento de ensino, entidade religiosa e espaço de esportes, conforme relatório policial e prova oral produzida em audiência, de modo que a pena deve ser aumentada em 1/6, a saber.

A ré preenche os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, vez que é primária, de bons antecedentes e não há informações nos autos de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa. Considerando o até aqui já apreciado para fixação de sua pena, a redução deve se dar na expressão intermediária (1/2).

Ausentes motivos idôneos, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um dias-multa), fixados estes no mínimo legal unitário.

Considerando o realinhamento da posição jurisprudencial (Tema 600), após o julgamento do REsp 1.329.088 sob o rito dos recursos repetitivos, o colegiado decidiu cancelar a súmula 512 - STJ, editada em 2014 (Súmula 512 - "A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas", o chamado tráfico privilegiado, definido pelo artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 não mais se enquadra às normas da Lei nº 8072/90).

Contudo, levando em conta a gravidade in concreto do delito praticado, a existência de circunstâncias judiciais negativas, a relevante quantidade de entorpecente, e a necessidade de atentar-se à prevenção geral, uma das funções da pena, deve ser fixado o regime semiaberto.

Fixo cada dia multa em 1/30 do salário mínimo diante de ausência de provas da possibilidade financeira do réu.

Incabível a substituição ou suspensão da pena privativa de liberdade: Embora no HC nº 97.256/RS, o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a inconstitucionalidade da vedação da conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos que constava dos arts. 33, §4º e 44 da Lei 11.343/06, entendo que a fixação de penas alternativas para o condenado pelo crime de tráfico fica reservada a hipóteses excepcionabilíssimas, em que as circunstâncias objetivas da conduta foram bastante favoráveis e as condições subjetivas do acusado passam confiança ao juízo de que o réu irá se afastar das drogas e as restrições impostas serão cumpridas a contento.

Assim, sequer é suficiente que a pena tenha sido fixada no mínimo, é preciso que fique comprovada (para além da presunção de inocência) a total inofensividade do agente. De outra forma, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal (art. 44, III do Código Penal). E, ausentes todos os requisitos para a aplicação do benefício, incabível a substituição.

Do mesmo modo, incabível suspensão condicional da pena, uma vez que ausentes os requisitos previstos no artigo 77, caput, e inciso I e II do CP.

As acusadas estão presas desde a data dos fatos, 03/06/2021, aproximadamente 10 (dez) meses, período inferior a 40% da pena cominada (art. 112, inciso V, da Lei 7.210/1984).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar as rés ERICA DE PROENÇA e KELEN GILMARA DE PROENÇA RODRIGUES, pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III, da Lei nº 11.343/2006 e, em consequência, condeno as rés a cumprir a pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime inicial semiaberto, e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um dias-multa), fixados estes no mínimo legal unitário.

Considerando o tempo decorrido desde a prisão das acusadas, em razão das limitações impostas pela pandemia vigente, e dado o regime de pena imposto, concedo-lhes o direito de apelar em liberdade.

Expeça-se com urgência os alvarás de soltura clausulados.

Desde já, fica autorizada a destruição da droga apreendida, com exceção de 0,2 gramas de cada substância, quantidade que ficará reservada para eventual contraprova. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito.

Custas pelas rés, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de

Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeçam-se mandados de prisão, e após guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Publique-se e intimem-se.

Itapeva, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA